

1501909-12.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... no local dos fatos ocorria a prática de tráfico de drogas. As características dos 03 autores foram passadas na denúncia. Com base nisso, visualizaram três indivíduos, sendo que um deles correu. O menor que correu foi identificado como Yuri, o qual informou que estava começando a prática de tráfico nesta data, sendo encontrado em seu poder um celular para comunicação. Com os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501909-12.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001417

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266747/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 20563066 - 03º D.P. DIADEMA, 3399/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2266747 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Richard da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

HENRIQUE RICHARD DA SILVA, qualificado às fls. 10 e 17/18, está sendo processado como incurso artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Santa Cruz, altura do nº. 01, bairro do Canhema, nesta cidade e comarca de Diadema, atuando previamente ajustado com os adolescentes Yuri Motta Souza (fls. 12 e 31) e Guilherme dos Santos David (fls. 13 e 32), unidos em desígnios e divisão de tarefas para o fim comum, traziam com eles e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 44 porções contendo 21,6g da droga cocaína, 83 porções contendo 18,1g da mesma droga, na forma de crack, e 58 embalagens plásticas contendo 75,8g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 19/20 e laudo de constatação provisória de fls. 27/30, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.54/57), o réu foi notificado e citado (fls.127), e apresentou defesa preliminar as fls. 130/132, através do Defensor Público que lhe foi nomeado, pugnando pela absolvição sumária, sem arrolar testemunhas diversas da Acusação. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 17/11/2021 (fl.135).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, com a confissão do réu, relativamente menor, concordando com a redução da pena em percentual mínimo, sem sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional semiaberto, com a perda do numerário apreendido, sem possibilidade de apelo em liberdade.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão e menoridade relativa, reduzindo a pena em patamar maior, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 19/20, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.27/30 e 174/176), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais (fls.5/6), receberam a denúncia de que no local dos fatos ocorria a prática de tráfico de drogas. As características dos 03 autores foram passadas na denúncia. Com base nisso, visualizaram três indivíduos, sendo que um deles correu. O menor que correu foi identificado como Yuri, o qual informou que estava começando a prática de tráfico nesta data, sendo encontrado em seu poder um celular para comunicação. Com os outros dois indivíduos, o menor Guilherme dos Santos David foi encontrada uma pochete com drogas e o maior/réu Henrique Richard da Silva foi encontrada uma segunda pochete, a qual continha drogas.

Sob o crivo do contraditório o policial Marcelo José de Lima alegou que veio uma denúncia via 190 de que no local dos fatos, ponto já conhecido pelo tráfico, haviam três rapazes traficando. Foram passadas as características deles. Ao chegarem lá, um dos indivíduos correu e foi detido, e os outros dois tinham duas pochetes e dentro delas foram localizados entorpecentes e dinheiro. O primeiro confessou ser olheiro. Questionados, confessaram que estavam mesmo traficando, que não moravam ali, só estavam traficando e cada um tinha uma função, um era olheiro e o maior de idade estava passando a função para o menor. Inclusive as características das vestes passadas também coincidiam. Reconhece o réu e com ele estava uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, e o outro também trazia com ele outra pochete com as mesmas drogas embaladas da mesma forma, além do dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes vendidos. Ao chegarem no local, o menor/olheiro, foi o

primeiro que correu e foi detido pelos outros policiais que fizeram o cerco, e então abordou o réu e o outro menor juntamente com o policial Pedro.

Igualmente o policial Pedro Martins veio uma ocorrência via 190 para a equipe e foram averiguar a denúncia de tráfico no local que já é conhecido como ponto de venda de drogas e as características físicas e vestes de dois ou três rapazes. Com Yuri, o primeiro que foi abordado, tinha dois aparelhos celulares, e com o réu e com o outro rapaz foram encontradas drogas e com os outros dois também. As características de todos coincidiam com eles. Com o réu tinha uma pochete preta e vermelha e tinham os três tipos de drogas mais comuns. O dinheiro estava com um dos rapazes menor de idade. Eles já foram falando "perdeu, já era". Reconhece o réu e com ele encontrou uma pochete com parte das drogas e ele admitiu o tráfico informalmente. Eles se conversavam entre si, como se fossem íntimos. Com o réu e com um dos menores tinha o mesmo tipo de droga, embaladas da mesma forma.

O adolescente Yuri Mota, extrajudicialmente (fl. 12), informou que a droga apreendida é de sua propriedade e estava no local praticando tráfico de drogas. Já o adolescente Guilherme David (fl.13) declarou à autoridade policial que estava apenas passando pelo local dos fatos e nada sabe informar a respeito dos fatos em apuração.

O réu, em solo policial (fl. 10) respondeu que não estava traficando no local e conhece o adolescente Yuri somente de vista.

Em juízo o acusado confessou que os menores estavam consigo e como seu pessoal estava precisando de dinheiro, foi traficar junto com os outros rapazes, um deles olheiro e o outro vendia as drogas junto consigo.

Logo, a confissão não é prova única e veio confirmada pelos relatos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, mesmo porque a denúncia anônima via Copom se mostrou verdadeira e que, de fato, os três indivíduos cujas características foram informadas estavam, de fato, praticando a traficância em conjunção de intenções e divisão de tarefas.

Ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Ademais, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, estava na companhia dos outros dois menores, e cada um desses, por sua vez, também traziam consigo ou drogas ou celular para comunicação entre si, a indicar o prévio ajuste entre eles e, ainda, a causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei especial, vez que a prática delitiva envolveu adolescentes, não se podendo dizer que o réu desconhecesse tal fato dado que ele tem praticamente a mesma idade que os rapazes e nunca admitiu ou afirmou desconhecer que eles fossem menores de 18 anos. Inclusive, a menoridade relativa vem comprovada documentalmente como se vê as fls. 12 e 13, o que basta.

Afasto, ainda, tese de situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ademais, não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Sobre o tema, já se decidiu: 'Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por

miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). E mais: TJ/SC - Desemprego não é motivo para excludente de ilicitude de tráfico 17/08/2021 - Admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. O entendimento serviu de base para a 5ª câmara Criminal do TJ/SC - Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030

Mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e crack), a quantidade de narcóticos (185 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a denúncia anônima que se mostrou verdadeira, são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (185 no total), ainda que se alegue que com o réu não estivesse esse montante todo, mas com fulcro no art. 29 do CP, ele responde em comparsaria, prévio ajuste e divisão de tarefas e divisão das drogas, justamente por se tratar de co-autoria e não de autoria colateral, esta sim a que se refere à hipótese de dois ou mais agentes praticarem o mesmo fato, mas de modo independente, e por isso cada um responde pela sua ação, mas não é essa a hipótese desses autos. Assim, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, ausente circunstância agravante, mas presentes as atenuantes da menoridade relativa (fl. 17) e da confissão a reduzir a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, aumento a pena em 1/6 conforme art. 40, VI da lei especial, dado que demonstradas as menoridades nos documentos de fls. 12 e 13, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa. E nem se alegue ausência de conhecimento acerca da menoridade dos comparsas, já que em nenhum momento o réu afirmou tal fato, até porque ele é relativamente menor, infrator inclusive, o que demonstra que seus comparsas tem a mesma idade, sendo de seu conhecimento tal fato que, como visto, está comprovado por documento hábil, e o que basta.

Quanto ao privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário, relativamente menor e confesso, mas considerando de outro lado o fato de que o crime em tela não foi um episódio isolado na vida do agente, quem já sofreu medidas sócio educativas (fls. 93) a indicar que faz do crime seu meio de vida, somado à quantia em dinheiro apreendida (fl. 19/20), demonstrativo de que vendas foram efetivamente feitas aos usuários, disseminando, propagando e contribuindo mais ainda para o vício, demonstrando maior dedicação à traficância,

ainda que o dinheiro não estivesse em seu poder quando de sua prisão, mas agindo em comparsaria (art. 29 do CP) a ele está vinculado também. Tudo acrescido da qualidade e natureza da droga, especialmente o crack e cocaína de alto poder viciante e degradante da saúde física e mental do usuário, opto pelo redutor de 1/3, totalizando a pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão mais 388 dias-multa. Neste sentido temos: Quantidade de drogas, por si só, basta para modular redutor de pena, diz STJ (07/10/2021) – É possível a valoração isolada da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 – neste último caso, assim, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Processo nº HC 685.184.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Contudo, entendo incabível, por insuficiente e ineficaz à reprovação da conduta do agente e à sua ressocialização, a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do CP, além de não ser socialmente recomendável diante da personalidade dissocial do agente a elevar sua culpabilidade, sob pena de se potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade, por violar mais intensamente o bem jurídico tutelado, quer pelo elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática do tráfico verdadeiro meio de vida, como no caso dos autos. Ademais: “ Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas (fl. 93), bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à

progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra HENRIQUE RICHARD DA SILVA, qualificado às fls. 10 e 17/18, como incurso artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal e o faço para condená-lo à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 388 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos (fl.19), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).
Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA